

1500837-61.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... drogas. Não sabia se o local era ponto de tráfico. Admitiu que, quando era menor, já traficou entorpecentes, alegando que fez isso porque estava precisando de dinheiro, mas depois parou de realizar o narcotráfico. Estava com R\$ 65,00, dinheiro que ganhou da sua mãe para pagar o UBER para a mulher e o filho menor. A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500837-61.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2156809/2022 - 02º D.P. PIRACICABA, 25462743 - 02º D.P. PIRACICABA, 2156809 - 02º D.P. PIRACICABA, 2156809/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FABIANO LIMA DA SILVA

Réu Preso

Contr. nº 2022/000665

Aos 29 de agosto de 2022, às 14:50 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu LUIZ FABIANO LIMA DA SILVA (PRESO CDP local). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: GM Francisco Dernival Miranda Júnior e GM Juvenal Estevão de Macedo. Presente(s) a(s) testemunha(s) de defesa: Washington Alves Soares, Anderson Fábio da Silva e Maria Aparecida da Silva.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per

si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (GM Francisco e GM Juvenal) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra a Defesa foi dito que desistia das oitiva(s) da(s) testemunha(s) Whashington, Anderson e Maria), o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).1. LUIZ FABIANO LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processados como incurso no artigo 33 c.c. o art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 8 de junho de 2022, por volta das 11 horas e 15 minutos, na rua Querubim Sampaio, altura do nº 280, bairro Jardim Planalto, nesta comarca, LUIZ FABIANO e o adolescente Washington Alves Soares (fls. 8), em concurso, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar: 1) 112 invólucros plásticos fechados por pó, com massa bruta de 34,77g, contendo cocaína na forma de pedras de "crack"; e 2) 130 microtubos plásticos do tipo eppendorf, com massa bruta de 199,59g, contendo cocaína em pó. É da inicial que o acusado e o adolescente se uniram para praticar o tráfico de drogas no local indicado. Na divisão de tarefas, LUIZ FABIANO atuava como olheiro e fazia a recolha do dinheiro; já Washington ficava com algumas porções de drogas em seu poder para as fornecer aos clientes. Na data dos fatos, guardas civis surpreenderam a dupla no conhecido ponto de tráfico, em atitude que reputaram suspeita. O acusado e o adolescente foram abordados e submetidos à revista, logrando-se encontrar, em poder daquele, R\$ 65,00 obtidos com o comércio de drogas e, em poder deste, 15 eppendorfs contendo cocaína. LUIZ FABIANO e o menor foram entrevistados e admitiram suas condutas ilícitas. Washington também mostrou aos servidores públicos onde a dupla tinha em depósito outras porções de droga, ou seja, à pequena distância do local da abordagem e sob uma pedra. Nesse local foram recolhidas 112 porções de "crack" e 115 eppendorfs de cocaína idênticos àqueles encontrados em poder do infrator. 2. O processo teve trâmite regular, cf. fls. 95, 108, 126/127 e 128/129. 3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, depoimentos colhidos e, especialmente, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudos de constatação de fls. 19/23 e toxicológico de fls. 101/103. 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Os Guardas Municipais Francisco e Juvenal contaram que estavam em patrulhamento preventivo e que, ao passar pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, avistaram dois indivíduos conversando. Estes, notando a presença da equipe, separaram-se, tomando sentidos opostos, em claro sinal de fuga. Ao realizarem a busca pessoal nos indivíduos, constataram que o adolescente trazia consigo 15 eppendorfs de cocaína e que LUIZ FABIANO tinha consigo a quantia de R\$ 65,00. os guardas, o adolescente contou que ambos ali estavam comercializando entorpecentes, além de indicar aos guardas onde havia mais porções de droga. Por fim, localizaram mais 112 pedras de crack e 115 eppendorfs de cocaína, sendo que a embalagem da cocaína era idêntica às apreendidas em poder de Washington. LUIZ FABIANO contou aos guardas que sua função no local era a de "olheiro", incumbindo-se de avisar ao adolescente a aproximação de policiais. Também ficava com dinheiro da venda das drogas. O GM Francisco acrescentou que, pela sua experiência, é comum a divisão de tarefas entre pessoas nos pontos de vendas de drogas. O caso foi atípico, pois réu e adolescente foram colaborativos e admitiram o envolvimento no tráfico. O GM Juvenal afirmou que o réu e o adolescente estavam conversando. Quando viram a viatura, separaram-se, tomando rumos diferentes, em "passos forçados". O local é conhecido como ponto de tráfico. Passam pelo local porque ali, à distância de um quarteirão, existe uma escola municipal. No interrogatório policial, LUIZ

FABIANO optou pelo silêncio. Em Juízo, o acusado disse que estava na rua esperando sua mulher. A viatura chegou e o menor se aproximou do interrogando, começando a “puxar assunto”. Foram “enquadrados” (sic). Os guardas conversaram com o menor do outro lado da rua. Quando voltaram, anunciaram que seriam presos. Não possuía drogas. O dinheiro apreendido lhe pertencia e foi dado pela sua mãe para pagar o Uber. No panorama dos autos, a condenação é de rigor. Ficou evidente, nos depoimentos dos servidores públicos, a responsabilidade do réu. Não há razão para duvidar do que disseram. De fato, nossas Cortes de Justiça avalizam os depoimentos de policiais, forte no entendimento de que seria um contrassenso acometê-los da difícil missão de atuar na prevenção e repressão de crimes para, em seguida, negar validade a seus relatos, justamente quando prestam conta em Juízo de seu sensível trabalho (sobre a validade da palavra dos policiais, cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2014). 5. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que o réu não possui antecedentes desabonadores, cf. fls. 96/98. Todavia, cuida-se de indivíduo que, desde a adolescência, dedica-se ao tráfico, cf. fls. 86/94. Além do mais, praticava o crime com menor e a apreensão diz respeito a significativa quantidade de droga. Nesse cenário, o privilégio é inviável. A causa de aumento articulada na denúncia ficou bem demonstrada. 6. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal, declarando-se perdido bens e valores apreendidos.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). LUIZ FABIANO LIMA DA SILVA vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada improcedente. Isso porque há flagrantes nulidades, que invalidam todo o caderno probatório produzido em desfavor do réu. Primeiro porque a prisão do réu decorreu de abordagem feita por guardas municipais que atuaram como verdadeiros integrantes das forças policiais, o que contraria o art. 144, CF, Afinal, o policiamento ostensivo, preventivo ou investigativo não é tarefa da GCM, conforme estabelece o art. 144, § 8º, da CF, sendo que no caso em tela, os próprios guardas declararam que abordaram o réu e adolescente porque entenderam que ambos evidenciaram atitude suspeita. Ocorre que, os guardas municipais, não tem competência para fazer esse tipo de diligência, pois a atuação deles deve guardar relação com a tutela de bens, serviços ou instalações municipais, o que não é o caso dos autos, que houve clara atuação visando o combate ao tráfico. E tampouco é possível justificar a atuação dos guardas municipais a partir do que dispõe o art. 301, do Código de Processo Penal, pois esse dispositivo é reservado apenas aos casos em que o flagrante é claro e perceptível de plano. Ou seja, só é possível que o cidadão comum atue, como verdadeira autodefesa da sociedade, em casos que não há dúvida de que o flagrante ocorre, isto independentemente de qualquer diligência investigativa prévia, como revista pessoal. Recentemente, aliás, o tema foi tratado pela Sexta Turma do STJ, (REsp. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). Entre diversos pontos, o Ministro Schietti Cruz explicou que “Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes”. Assim, pela clara falta de competência, o ato já deve ser considerado ilegal e o réu absolvido por ausência de provas válidas. Porém, não é só. Isso porque ainda que os

guardas municipais possuíssem autorização para sair realizando abordagens de pessoas suspeitas, verifica-se que no presente caso não havia justa causa para a realização da revista pessoal. Afinal, os guardas alegaram que fizeram a abordagem em função do “nervosismo” do acusado e adolescente. Não fizeram, assim, alusão a qualquer ato típico de traficância e nem mencionaram qualquer dado objetivo que justificasse a medida invasiva, que se deu a partir da mera intuição deles. Dessa forma, no caso em tela, antes da abordagem, não existia qualquer dado concreto – e objetivamente aferível – de que o réu estaria praticando o crime de tráfico de entorpecente (ou qualquer outro delito). A abordagem dele se deu mediante critério meramente subjetivo o que não é suficiente para autorizar a busca pessoal, sob pena de violação ao direito constitucional à intimidade (art. 5º, X, CF). Recentemente, aliás, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu como ilegal a busca pessoal efetuada após um suposto “nervosismo” da pessoa abordada – parâmetro puramente subjetivo: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. 2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no “nervosismo” apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal. 4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (STJ - HC 659.689/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). Nem mesmo a fuga do agente justificaria a atuação dos guardas municipais: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. No caso dos autos, a busca pessoal foi efetuada porque o Paciente era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes, tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial e teria se comportado de “modo suspeito”. Como se vê, não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da medida invasiva. 2. Os arts. 240, § 2.º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Esta fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do “sentimento”, “intuição” ou o “tirocínio” do agente policial que a executa. 3. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas. A propósito, nem mesmo o histórico criminal mencionado no acórdão impugnado legitima a diligência policial, pois, na hipótese, não havia fundada suspeita de que o Acusado estava na posse do entorpecente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Acusado da imputação feita na Ação Penal n. 0700426-55.2021.8.02.0049 ” (STJ - HC n. 737.075/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.). Na verdade, quando o responsável pela prisão apresenta argumentos genéricos como “atitude suspeita”, “nervosismo” ou “tentativa de evasão” para justificar sua atuação, ele dá margem para que se entenda que a ação foi pautada por juízos discriminatórios, o que evidentemente é

ilegal. Portanto, seja por extrapolarem as atribuições constitucionais, seja porque não atenderam os requisitos legais para o ato, conclui-se que a ação dos guardas municipais deve ser considerada ilícita, nos termos do art. 157, caput, do CPP, pois a um só tempo ocorreram violações a normas legais e constitucionais (art. 240, § 2º, CPP, e arts. 5º, X, 144, § 8º, CF). E, por conseguinte, todas as demais provas decorrentes dessa busca irregular também devem ser consideradas ilegais, consoante § 1º, também do art. 157, do CPP: "São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras". Afinal, é evidente o nexo de causalidade. Logo, por falta de provas válidas, requer-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II ou VII, do CPP. Caso, no entanto, fique superada essa primeira tese defensiva, a absolvição do acusado se impõe por falta de provas quanto à autoria delitiva. Afinal, os elementos reunidos ao longo da persecução penal não esclareceram se o réu estava praticando o tráfico de drogas. Ele negou o crime, alegando que estava ali aguardando a chegada de outras pessoas. Já os guardas municipais informaram que patrulhavam pelo local dos fatos quando viram o réu e adolescente conversando. Realizada a abordagem (ilegal), encontraram em poder do adolescente algumas porções de drogas. Com o acusado, apenas dinheiro. Depois, realizada varredura no local, encontraram mais substâncias entorpecentes. O réu, segundo eles, seria o olheiro e responsável por recolher o dinheiro. Essa informação teria sido dada pelo próprio réu. Ora, a substância entorpecente foi apreendida com o adolescente e não com o réu. A alegação de que seria "olheiro" é apenas fundada numa suposta confissão informal, que não possui qualquer legalidade. Logo, não se pode afastar a alegação do réu de que estava ali apenas para adquirir substância entorpecente, motivo pelo qual deve ser

absolvido pela mais absoluta falta de provas quanto à autoria delitiva. No entanto, caso o entendimento seja pela condenação, requer-se seja a pena fixada no mínimo legal, bem como seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Presentes os requisitos legais, pugna-se pela aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com suas implicações. O fato do réu possuir uma única anotação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico não obsta a aplicação da minorante, pois incapaz de comprovar a dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido já decidiu a Suprema Corte: "O ato infracional cometido pelo agente quando inimputável não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação à atividades criminosas, principalmente quando inexistem nos autos provas de práticas delitivas reiteradas." (HC 179.159, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.12.2019). Caso não reconhecido o "tráfico privilegiado", requer-se seja, ao menos, fixado o regime semiaberto. Por fim, não subsistindo mais os requisitos da prisão preventiva, requer-se seja autorizado ao réu que recorra em liberdade. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

LUIZ FABIANO LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 8 de junho de 2022, por volta das 11 horas e 15 minutos, na rua Querubim Sampaio, altura do nº 280, bairro Jardim Planalto, nesta comarca, e o adolescente W. A. S. (fls. 8), em concurso, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 112 invólucros plásticos fechados por pó, com massa bruta de 34,77g, contendo cocaína na forma de pedras de "crack", e 130 microtubos plásticos do tipo eppendorf, com massa bruta de 199,59g, contendo cocaína em pó.

Narra a denúncia que o acusado e o adolescente se uniram para praticar o tráfico de drogas no local indicado. Na divisão de tarefas, o réu atuava como olheiro e fazia a recolha do dinheiro, enquanto W. ficava com algumas porções de drogas em seu poder para fornecê-las aos clientes.

Narra, ademais, que, na data dos fatos, guardas civis surpreenderam a dupla no conhecido ponto de tráfico, em atitude que reputaram suspeita. O réu e o adolescente foram abordados e submetidos à revista, logrando-se encontrar, em poder

daquele, R\$65,00 obtidos com o comércio de drogas e, em poder deste, 15 eppendorfs contendo cocaína.

Narra, por fim, que o acusado e o menor foram entrevistados e admitiram suas condutas ilícitas. W. também mostrou aos servidores públicos onde a dupla tinha em depósito outras porções de droga, ou seja, à pequena distância do local da abordagem e sob uma pedra. Nesse local foram recolhidas 112 porções de "crack" e 115 eppendorfs de cocaína idênticos àqueles encontrados em poder do infrator.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 108). Defesa preliminar apresentada às fls. 112/119. Após, a denúncia foi recebida (fls. 128) e o réu foi citado (fls. 117/118).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes e o reconhecimento da causa de aumento de envolvimento de menor na prática do crime, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pleiteou a absolvição, arguindo ilicitude da ação dos guardas civis e sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu.

É o relatório.

Decido.

Afasto a tese defensiva de que houve ilicitude na ação dos guardas civis e, consequentemente, nulidade da prova.

Os guardas civis integram os quadros funcionais do Município, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal. Como atuação secundária, cabe aos guardas civis a defesa da população local, compreendida a repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso assim não ajam, respondem na forma do artigo 13, §2º, "a", do Código Penal, por omissão imprópria, pois têm o dever de agir, na medida em que a lei obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além disso, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de Segurança o dever legal.

Desta forma, é conferida à Guarda Civil a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

Registre-se, ainda, que em 2014 foi sancionada a Lei 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Referido diploma legal institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

A Lei 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas as leis municipais que tratem sobre suas respectivas guardas, posto que cada Município deve editar a sua própria lei, adequando-se às disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais. A importância dessa Lei encontra-se no fato de que amplia a restrição interpretada que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

De fato, dispõe esta norma constitucional que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A interpretação restritiva encontra-se no fato de que as Guardas Municipais sempre tiveram um papel relacionado com a proteção do patrimônio municipal. A Lei 13.022/14 amplia a interpretação, estabelecendo que as Guardas Municipais podem colaborar com os demais Órgãos de segurança pública, no caso as Polícias Civil e Militar.

Isso se depreende das competências que a Lei confere às Guardas Municipais. O artigo 4º atribui a competência geral, qual seja, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, conforme já previsto na Constituição Federal. Por outro lado, o artigo 5º adjudica as competências específicas. E é entre as competências específicas que podemos destacar que as Guardas Municipais não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também lhes são atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz

social.

Outrossim, não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei 13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do artigo 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o artigo 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer às competências dos Órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos. Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

Ainda que assim não fosse, não haveria a alegada ilicitude.

Embora a Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8º, ao elencar as funções da Guarda Municipal, não cite a atribuição de polícia ostensiva, isto não importa em vedação a que prendam em flagrante suspeitos, bem assim que apreendam bens relacionados ao delito praticado.

Conforme revelou a prova que a seguir será analisada, a equipe da guarda civil passou pelo local dos fatos, o qual era bastante conhecido como ponto de tráfico de drogas, e viu o réu e o adolescente ali parados conversando e perceberam que ambos agiram de forma suspeita da prática de tal delito ao notarem a presença da guarda, demonstrando nervosismo, separando-se rapidamente e tomaram sentidos opostos em passos apertados, em evidente sinal de fuga. Diante disso, abordaram-nos e com o menor localizaram parte das drogas e com o réu dinheiro em notas trocadas. Ambos admitiram que estavam no local realizando o tráfico de drogas e, inclusive, apontaram o local onde ocultavam o restante da cocaína e do “crack” apreendidos. Registre-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante aquele que está cometendo crime, inexistindo óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais. Neste sentido, diversos julgados do E. TJSP:

“Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público - Condenação. Cabível - Nulidade da apreensão realizada por guarda municipal - Não acolhida - Possibilidade da ação dos guardas municipais - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal e artigo 5º da Lei 13.022/14 - Aos guardas-civis, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, tendo flagrado a ré em conduta clara e suspeita, em local conhecido pela prática do narcotráfico, sendo certo que a omissão dos agentes poderia levar à eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. Desnecessidade de critérios rígidos para realização de busca pessoal. A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que a apelada foi abordada e presa em situação de flagrante na via pública e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade ante a fundada suspeita de que estava na posse de objetos ilícitos circunstância que dispensa a necessidade de mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do CPP e que se confirmou com a apreensão dos psicotrópicos. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos agentes da lei harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar a acusada. Os guardas municipais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. Negativa da ré restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar a ré da condenação. Prova da finalidade de entrega a terceiros advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. É certo que a prova da mercancia não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Pena-base mantida em seu patamar mínimo legal. Aplicada a causa de redução do artigo 33, § 4º, da Lei nº

11.343/06. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direitos - Inviável - Requisitos do benefício não foram satisfeitos. Regime inicial semiaberto. Regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade da autora. Recurso parcialmente provido." (TJSP - Apelação Criminal 1519489-12.2021.8.26.0228. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho - j. 24/08/2022) - g.n.

"PROCESSO-CRIME - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR GUARDA CIVIL MUNICIPAL - "PATRULHAMENTO ROTINEIRO - AVISTAMENTO DE VEÍCULO DENUNCIADO PELA DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS MINUTOS ANTES - ABORDAGEM QUE SE FAZIA OBRIGATÓRIA - HIPÓTESE DE FLAGRANTE - SITUAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA OU INVESTIGATIVA - LEGITIMIDADE DE QUALQUER DO POVO REALIZAR A PRISÃO EM FLAGRANTE - ART. 301, DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP - Apelação Criminal 1500202-11.2021.8.26.0601. 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Jayme Walmer de Freitas - j. 22/08/2022) - g.n.

"Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes - Sentença condenatória - Preliminares de nulidade em face: (i) do indeferimento de realização de incidente de dependência toxicológica; (ii) da alegada ilicitude da prova colhida mediante suposta invasão de domicílio; e (iii) da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais - Rejeição - Dúvida sobre a higidez mental ou dependência química do acusado, ao tempo dos fatos, não demonstrada - Decisão que indeferiu a diligência com manifestação suficiente - Hipótese de crime permanente - Situação de flagrância que se protraí no tempo - Não há que se cogitar de prova ilícita por violação de domicílio, máxime para efetuar prisão em flagrante - Busca e apreensão realizada por guardas municipais, realizadas de forma regular - No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, o reconhecimento da atenuante da confissão, a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a concessão do privilégio contido no artigo 33, parágrafo 4º, da lei antedita, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional - Admissibilidade parcial - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Depoimentos de guardas municipais importantes na elucidação dos fatos - Condenação acertada, diante de acervo probatório robusto e convincente - Penas-base reduzidas - Afastada causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Grande quantidade de droga a ser considerada, somente, na terceira etapa da dosimetria, inclusive para justificar o afastamento da causa de diminuição - Privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, não compatível com o contexto dos autos - Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Repercussão concreta da conduta do agente - Regime prisional fechado mantido. Recurso parcialmente provido." (TJSP - Apelação Criminal 1501017-81.2019.8.26.0567. 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi - j. 23/08/2022) - g.n.

"Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Recurso defensivo buscando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão feita pelos Guardas Municipais. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, afastamento da agravante da calamidade pública, reconhecimento da menoridade, e aplicação do redutor de pena, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial mais brando. Preliminar afastada - Ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais. Inocorrência - Crime de tráfico de drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Neste caso, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. Ademais, qualquer pessoa do povo pode realizar prisões em flagrante (art. 301, do CPP). Mérito - Autoria e materialidade comprovadas - Apreensão de 12 porções de cocaína na forma de crack (peso líquido

439,9 gramas). Guardas Municipais que relataram como ocorreu a prisão em flagrante e a apreensão das drogas. Condenação que se impõe. Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, afastamento da circunstância agravante da pandemia, e compensação entre a atenuante da menoridade com a agravante da reincidência. Não cabimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 por falta de amparo legal. Réu reincidente. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais. Preliminar rejeitada. Recurso defensivo parcialmente provido, para afastar a agravante da pandemia e reduzir a pena nos termos deste voto” (TJSP - Apelação Criminal 1522530-84.2021.8.26.0228. 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Ely Amioka - j. 24/08/2022) – g.n.

“APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença absolutória, que reconheceu a nulidade da abordagem do réu por guardas civis – Irresignação ministerial – Inocorrência de ilegalidade – Abordagem pessoal do réu realizada pelos guardas civis municipais motivada por fundada suspeita – Legitimidade e constitucionalidade da conduta dos guardas civis à luz do disposto no artigo 144, § 8º, da CF – Inteligência do art. 301, CPP – Mérito – Pedido de condenação do réu nas penas do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 – Possibilidade – Materialidade do delito comprovada pela apreensão das substâncias e alta quantia em dinheiro e constatação da presença dos respectivos princípios ativos atestada por laudo químico toxicológico – Testemunho harmônico e coerente dos guardas municipais com os demais elementos colhidos na fase policial e instrução criminal que desmentem a negativa de autoria do réu – Condenação do réu, que é de rigor – Dosimetria – Primeira fase – Pena fixada no mínimo legal – Natureza e quantidade de drogas que não transbordam o tipo – Segunda fase – Reincidência que deve ensejar aumento de 1/6 – Terceira fase – Não incidência da causa da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante ao não preenchimento dos requisitos legais – Apelante reincidente – Regime fechado fixado como inicial cumprimento de pena – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão da pena afastadas. Apelação parcialmente provida, para julgar procedente a ação penal e condenar o réu à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 (TJSP - Apelação Criminal 1502274-06.2020.8.26.0536.

Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Renato Genzani Filho - j. 19/08/2022) – g.n.

O C. STF também se manifestou recentemente no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (STF - HC 212635 - AgR. - Primeira Turma - Relator(a): CÁRMEN LÚCIA - j. 11/04/2022).

No mérito, a denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 11/13;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e fotografia de fls. 24;
- 3) termo de compromisso e responsabilidade de fls. 08 e cópia do RG de fls. 28, documentos que comprovam a menoridade de Washington;
- 4) laudo de constatação preliminar de fls. 19/23 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 101/103, os quais atestaram resultado positivo para cocaína em relação a todas as substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 09), o réu exerceu o direito de permanecer em silêncio. Interrogado em juízo (gravação), o réu negou o crime. Disse que, no dia dos fatos, estava na rua com a amiga da mulher, esperando-a chegar com sua filha menor. O menor W. também estava na rua. Quando viu a viatura, W. se aproximou para

conversarem. Neste momento, os guardas também se aproximaram e os abordaram. Pediram para a mulher se retirar. Eles o colocaram de um lado da rua e o menor em outro lado. Mostraram-lhe uma foto de uma pessoa morta, perguntaram se a conhecia e disseram se queria ser morto também. Depois, algemaram ele e o menor e os colocaram na viatura. Disse que não possuía drogas. Não sabia se o local era ponto de tráfico. Admitiu que, quando era menor, já traficou entorpecentes, alegando que fez isso porque estava precisando de dinheiro, mas depois parou de realizar o narcotráfico. Estava com R\$ 65,00, dinheiro que ganhou da sua mãe para pagar o UBER para a mulher e o filho menor.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o guarda civil Francisco Dernival Miranda Junior declarou que, no dia dos fatos, ele e seu colega de farda passavam pelo local descrito na denúncia, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu e o adolescente W. conversando. Informou que, quando os dois notaram a presença da equipe da guarda, rapidamente se separaram e tomaram sentidos opostos, com passos rápidos, em evidente sinal de fuga e demonstrando nervosismo. Diante da conduta suspeita, típica de tráfico de drogas, efetuaram a abordagem de ambos. Na posse do adolescente encontraram 15 eppendorfs de cocaína e, em poder do réu, apreenderam R\$ 65,00 reais em notas trocadas. Indagado, o adolescente admitiu que estavam realizando o comércio ilegal dos entorpecentes e, espontaneamente, apontou o local onde ocultavam o restante das drogas, distante cerca de 40 metros da abordagem. Lá, sob uma pedra de concreto, encontraram 112 pedras de "crack" e 115 eppendorfs de cocaína. Sustentou que as embalagens de cocaína eram idênticas às drogas apreendidas em poder do menor. O acusado, informalmente, confessou-lhes que sua função no comércio ilícito era a de "olheiro", ou seja, era responsável por avisar o adolescente caso percebesse a chegada da polícia, bem como ficava na posse do dinheiro da venda das drogas. Diante disso, deram voz de prisão ao réu e de apreensão ao menor. Explicou que, atualmente, é muito comum a atuação dos traficantes da forma como ocorreu no caso dos autos, ou seja, um fica com o dinheiro e o outro com parte das drogas, ficando a maior parte dos entorpecentes escondidos nas proximidades.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 05) e sob o crivo do contraditório (gravação) pelo guarda civil Juvenal Estevão de Macedo, o qual afirmou que o réu e o adolescente foram entrevistados separadamente. Próximo do local havia uma escola municipal e, por isso, passavam por ali rotineiramente. Anoto que os relatos dos guardas civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao

modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra de agente público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu e o adolescente traziam com eles e tinham em depósito as drogas descritas na denúncia, para fins de mercancia, substâncias estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De fato, a negativa do réu foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos guardas civis no sentido de que, em patrulhamento de rotina, depararam-se com o acusado e com o adolescente parados, conversando, no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, bem como que, ao perceberem a presença da viatura, eles se separaram e passaram a caminhar rapidamente em sentidos opostos, demonstrando nervosismo e visando evitar uma abordagem policial.

Na sequência, foram abordados e com o menor localizaram parte das drogas, ou seja,

15 eppendorfs de cocaína e, com o réu, dinheiro em notas trocadas.

Ademais, ao serem indagados, ambos confessaram informalmente a prática do comércio ilícito de drogas no local, tendo o adolescente apontado o local onde ocultavam o restante das drogas, acerca de 40 metros da abordagem, sob uma pedra de concreto, onde localizaram 112 pedras de "crack" e 115 eppendorfs de cocaína, esta última espécie embalada de forma idêntica às drogas apreendidas em poder do menor, bem como o réu admitiu que atuava como "olheiro", avisando o adolescente em caso de aproximação da polícia, além de ser o responsável por ficar na posse do dinheiro da venda das drogas.

Registro que a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes relacionadas ao réu e ao adolescente confirmam o destino mercantil, pois incompatíveis com a situação de meros usuários.

Some-se a isso o fato de os entorpecentes estarem embalados da forma como comumente são comercializados, bem assim o fato de ter sido apreendida quantia em dinheiro (R\$65,00), em notas trocadas (fls. 24), o que, aliado à falta de comprovação idônea por parte da Defesa, da origem lícita, faz presumir decorrer do comércio ilegal e confirma o destino mercantil dos entorpecentes, ensejando, inclusive, seu perdimento para a União.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20